



CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione VI civile

R.G. 5473/2019

All'udienza collegiale del giorno 16/09/2025 ore 10:50

Presidente Dott. Alberto Tilocca

Consigliere Dott. Giulia Spadaro

Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzerà

Chiamata la causa

Appellante/i

Controparte_1

Avv. BELLONI FEDERICO presente

Avv. BELLONI ANTONIO

Controparte_2

CP_3

CP_4

Avv. BELLONI FEDERICO

Avv. BELLONI ANTONIO

Appellato/i

Controparte_5

Avv. ZINGARELLI LUIGI presente

Avv. ZINGARELLI NICOLA

La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.

L'avv. Belloni rifiuta il contraddittorio su domande ed eccezione nuove e chiede lo stralcio dei documenti e memorie depositate dalla controparte dopo la rinuncia al mandato del 30/09/2022, riportandosi ai propri atti.

L'avv. Zingarelli si riporta ai propri atti e proprie eccezioni e domande e fa presente che non sono presente i fascicoli cartacei del primo grado e del precedente grado d'appello.

La Corte

trattiene la causa in decisione

IL PRESIDENTE

Dr Alberto Tilocca

Martina Bianchi

Assistente giudiziario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE

composta dai magistrati:

dr. Alberto Tilocca - Presidente
dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere
dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore

all'udienza del **16 settembre 2025** ha pronunciato - ai sensi dell'**art. 281-sexies c.p.c.** - la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. **5473/2019** del registro generale degli affari contenziosi vertente

tra

Controparte_1 (C.F. *CodiceFiscale_1*), in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale (P. IVA *P.IVA_1*), rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avvocati Antonio Belloni (C.F. *CodiceFiscale_2*) e Federico Belloni (C.F. *C.F._3* [...]), ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cassia n. 240, presso l'avv. Federico Belloni, giusta delega in atti

- ATTORE IN RIASSUNZIONE –

E

Controparte_5 (C.F. *C.F._4*), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Zingarelli (C.F. *C.F._5*) ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale *Email_1* giusta delega in atti

- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE–

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Controparte_1 in proprio e quale titolare dell'omonima impresa edile, ha evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Rieti sua cugina *Controparte_5* per sentirla condannare al pagamento del saldo prezzo, in relazione all' appalto per la realizzazione su terreno comune di un fabbricato, al

risarcimento del danno per l'inadempimento da parte della CP_5 nel pagamento del prezzo pattuito e per sentir dichiarare la divisione del bene comune tra le parti. Ha resistito la CP_5 contestando la fondatezza delle avverse pretese, specialmente quella di divisione del bene comune e svolgendo, al contempo, domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore con le conseguenti restituzioni ed il ristoro dei danni. L'attore ha modificato la sua originaria domanda di adempimento del contratto in risoluzione per inadempimento della CP_5. Il Tribunale di Rieti, ad esito dell'istruttoria, ha dichiarato risolto il contratto d'appalto per inadempimento della CP_5 accertando l'entità dei pagamenti dalla stessa nelle more eseguiti, e rigettato ogni altra domanda mossa dalle parti, ritenendo inammissibile, la domanda di divisione del bene comune.

Avverso la sentenza ha proposto gravame il CP_1 ed appello incidentale la CP_5.

La Corte romana adita, con una prima sentenza non definitiva recante n° 2106/10 pubblicata in data 1.12.2009, ha così disposto: *“condanna Controparte_5 al pagamento in favore di Controparte_1 della complessiva somma di euro 32.536,78, oltre interessi nella misura e decorrenza indicate in motivazione; rigetta l'appello incidentale; dispone la prosecuzione del giudizio di divisione per l'ulteriore istruttoria, come da separata ordinanza; spese al definitivo”*.

La sentenza è così motivata: *“L'appellante CP_1 censura in primo luogo la sentenza del tribunale per avere erroneamente applicato l'art. 1453 secondo comma c.c., con il conseguente rigetto della domanda di pagamento delle prestazioni da esso attore eseguite, senza espressa eccezione della controparte e comunque senza considerare che l'azione di risoluzione per inadempimento deve consentire alla parte adempiente di recuperare la prestazione eseguita.*

Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il tribunale abbia imputato il versamento di lire 56.000.000 eseguito dal padre della CP_5 come acconto del corrispettivo dell'appalto dovutogli da quest'ultima, senza però disporre la restituzione dell'assegno di pari importo da esso attore rilasciato a garanzia al CP_5

Il CP_1 lamenta ancora il mancato accoglimento della sua domanda di risarcimento danni per avere il tribunale erroneamente attribuito il mancato completamento del fabbricato non già all'inadempimento della CP_5 bensì alla circostanza che la concessione in sanatoria fosse stata rilasciata solo nel 2001.

L'appellante deduce quindi l'erroneità della pronuncia di inammissibilità della domanda di divisione del fondo e del fabbricato, per la transazione intervenuta tra le parti in data 11-7-1992 in un precedente giudizio di divisione, senza precisare se il decorso del termine di dieci anni previsto dall'art. 1111 c.c. debba considerarsi come presupposto processuale ovvero più esattamente come

condizione dell'azione, e senza valutare la sussistenza dei gravi motivi consistenti nell'insanabile dissidio tra le parti.

Da ultimo il CP_1 lamenta l'erronea integrale compensazione delle spese processuali, nonostante la soccombenza sia pure parziale della convenuta CP_5

La CP_5 dal canto suo, con l'appello incidentale proposto, deduce in primo luogo che l'indivisibilità del lotto, riconosciuta dal tribunale, deriva dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Rieti che tale indivisibilità aveva affermato, e non già dal mancato decorso del decennio previsto dall'art. 1111 c.c., costituente comunque un vero e proprio presupposto processuale, e non una condizione dell'azione come ipotizzato da parte appellante.

Con il secondo motivo l'appellante incidentale lamenta la erroneità della pronuncia di risoluzione per colpa di essa committente, conseguente alla errata valutazione delle prove acquisite in ordine alla responsabilità delle modifiche al progetto e delle varianti apportate all'opera eseguita, e che non aveva tenuto conto che essa CP_5 quale coappaltatrice con il cugino Controparte_1, era tenuta al pagamento del solo 50% del corrispettivo dovuto all' Controparte_6 ribadiva pertanto la domanda di risoluzione del contratto per l'inadempienza del CP_1 a motivo delle variazioni da esso indebitamente apportate all'opera. Ribadiva quindi in particolare la eccepita nullità della CTU, in quanto depositata oltre il termine fissato dal giudice e fondata su documenti forniti dalla controparte nel corso dello svolgimento delle operazioni.

Da ultimo la CP_5 lamenta che tribunale aveva ignorato il disposto degli artt.1659 e 1661c.c. che prevedono che le varianti debbano essere autorizzate per iscritto, con la conseguente inammissibilità delle prove orali espletate nonostante il divieto sancito in dette norme.

Le censure delle parti, tutte strettamente connesse, vanno esaminate congiuntamente.

Con il contratto di appalto del 13-7-1992 in atti, Controparte_1 e Controparte_5 davano in appalto alla Controparte_7 con sede in Cantalice la costruzione delle strutture in cemento armato di una palazzina di civile abitazione ubicata in Santa Rufina di Cittaducale, da realizzarsi su un lotto di cui sono comproprietari, pattuendo un corrispettivo parte a corpo (importo forfettario di lire 105.000.000), parte a misura. L'opera non venne però completata, a causa dei gravi dissidi insorti tra le parti, in quanto la CP_5 interrompeva i pagamenti dovuti a causa di pretesi vizi e per le difformità dell'opera eseguita dall'appaltatore CP_1 e la controversia dava luogo ad una intricata vicenda giudiziaria, di cui è parte il presente procedimento.

Preliminarmente, occorre respingere espressamente l'eccezione sollevata dalla CP_5 di nullità delle CTU espletate, già implicitamente disattesa nella sentenza impugnata, anche alla luce di tutti i provvedimenti adottati dal giudice istruttore. In proposito, deve ricordarsi il principio di tassatività delle nullità processuali sancito chiaramente dall'art.156 c.p.c. Orbene, nessuna nullità è prevista

per il ritardato deposito dell'elaborato peritale, pure in difetto della richiesta di proroga, la cui eventuale omissione potrà semmai dare luogo a sanzioni di carattere disciplinare a carico del CTU o incidere sul compenso da liquidare al medesimo. Allo stesso modo, per il caso che il CTU ritenga di dovere esaminare documenti non ritualmente prodotti in giudizio dalle parti -circostanza peraltro neppure specificatamente accertata nel caso di specie, attesa la genericità della eccezione sollevata in proposito dalla CP_5 il codice di rito non commina alcuna nullità, sempre che venga rispettato il principio del contraddittorio.

In linea di principio il CTU in base al disposto della prima parte dell'art.194 c.p.c., ha il potere-dovere di assumere, anche senza specifica autorizzazione del giudice ogni elemento necessario per rispondere ai quesiti, ma sempre che si tratti di dati accessori, rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti o situazioni che, in quanto posti direttamente a fondamento delle domande ed eccezioni delle parti debbono essere da queste provati (v.Cass.23 marzo 1998 n.2543): infatti la C.T.U. ha la funzione di rendere possibili quelle valutazioni e quegli accertamenti che, per essere operati, richiedono necessariamente specifiche cognizioni tecnico-scientifiche, mentre da essa esula del tutto la finalità di supplire alle deficienze probatorie della parte (v. Cass. sez. II 23 ottobre 1997 n.10415). Sempre in base all'art.194 c.p.c. il C.T.U., nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, anche senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti in modo da permettere il controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice (Cass. sez. II 11 marzo 1995 n.2865). Nella ipotesi in esame non si tratta di consentire alle parti di produrre documenti oltre il termine perentorio di cui all'art. 184c.p.c., eludendo la relativa preclusione, e neppure di rimettere indebitamente in termini le parti per una ulteriore produzione documentale suggerita dal C.T.U., bensì di dare modo allo stesso C.T.U., di rispondere ai quesiti formulati dal Tribunale, ricercando anche presso i competenti uffici pubblici, e mediante lo svolgimento di personali indagini espressamente indicate nell'elaborato peritale, il materiale e la documentazione all'uopo strettamente necessaria, anche al di fuori di quella già versata in atti dalle parti, senza per questo consentire alcun ampliamento del thema decidendum e neppure del thema probandum, ormai definitivamente fissati nei termini perentori dettati dal codice di rito.

Fatta questa necessaria premessa, la Corte ritiene di dover condividere le risultanze della seconda CTU congruamente motivata ed immune da vizi logici e scientifici, che ha in gran parte ribadito le conclusioni del precedente elaborato in atti. Il consulente all'esito di una accurata indagine, svolta sempre nel contraddittorio con i ctp, ha accertato l'avvenuta esecuzione di tutte le opere da pagarsi a forfait, in base alle previsioni del contratto di appalto del 13-7-1992 e di alcune delle opere per le

quali si era previsto il pagamento "a misura", ed in particolare delle tamponature esterne e tramezzature interne, ed inoltre la realizzazione di taluni lavori non previsti nel contratto, quali le fondazioni, i solai del seminterrato e dei piani superiori, canne fumarie e comignoli, piano sottotetto e altri lavori come montanti e correnti metallici per ringhiere, terrazzi, canali di gronda, fossa biologica, pozzetti vari, impermeabilizzazioni, stimando quindi il corrispettivo spettante all'Impresa appaltatrice sulla base dei prezzi contrattuali e del prezziario regionale del 20-5-1993, in complessive lire 298.927.726. Lo stesso CTU ha accertato poi l'esistenza di alcune difformità rispetto al progetto iniziale, considerandone anche l'incidenza negativa sulla determinazione del corrispettivo totale, come nel caso della variazione del solaio realizzato in laterocemento poggianti sulle travi di fondazione, anziché mediante riempimento in breccia sulla fondazione con sovrastante soletta in calcestruzzo, ed ha poi chiarito che tutte le difformità o varianti realizzate "sono state regolarmente condonate con il rilascio di concessione in sanatoria. La CTU ha poi nella sostanza escluso la sussistenza di vizi e difetti dell'opera realizzata dal CP_1 rilevanti ai sensi dell'art. 1667c.c., peraltro del tutto genericamente denunciati dalla CP_5 che sembra in realtà lamentare più che altro le difformità del fabbricato rispetto al progetto originario.

Se il corrispettivo dell'opera realizzata è stato stimato dal CTU in circa lire 300.000.000 (somma questa in sostanza corrispondente a quella indicata dal CP_1 nell'atto introduttivo del giudizio) e se -come ha esattamente rilevato il primo giudice- la convenuta CP_5 aveva versato in totale la somma di lire 87.000.000, residua un debito di lire 63.000.000 a carico della appellata, CP_5. Deve infatti ritenersi che l'importo totale del corrispettivo dovuto per l'opera eseguita debba essere diviso al 50% tra i due committenti che congiuntamente conferirono l'appalto all'impresa CP_1 con il contratto del 13-7-1992, e non può pertanto condividersi l'affermazione della sentenza di primo grado che aveva determinato il debito della convenuta in lire 168.000.000 circa, con un calcolo certamente errato (il tribunale ha ritenuto che l'intero corrispettivo di lire 105.000.000 pattuito a forfait fosse a carico della CP_5 e vi ha aggiunto l'importo di lire 150.000.000 corrispondente al 50% dei 300.000.000 riferiti "alle opere extracontrattuali", e dalla somma di lire 255.000.000 ha detratto l'importo versato dalla CP_5 di lire 87.000.000).

Da un attento esame della CTU si evince infatti con chiarezza che tutte le opere realizzate dalla Impresa appaltatrice sono state valutate complessivamente lire 300.000.000 circa, importo comprensivo sia delle opere a forfait, che di quelle a misura e di alcuni lavori non previsti in contratto, il cui valore è peraltro modesto in relazione all'importo totale indicato dal CTU. Deve sottolinearsi che in realtà lo stesso appellante CP_1 riconosce che l'inadempimento della cugina CP_5 è limitato alla somma sopra indicata di lire 63.000.000 (v.pag.6 comparsa conclusionale di p. appellante depositata il 5-11-2008), con dichiarazione cui può attribuirsi efficacia confessoria in

senso lato, sebbene proveniente dal suo procuratore, sia in ordine alla determinazione del proprio credito, sia in ordine all'effettivo incasso e alla imputazione in conto lavori da parte sua della somma di lire 56.000.000 versatagli dal padre della CP_5 a garanzia della quale egli ebbe a rilasciare l'assegno bancario di cui pretende la restituzione. Si tratta dunque di un inadempimento certamente grave, per essere la committente rimasta debitrice di oltre il 40% della quota del corrispettivo da essa dovuta all'impresa appaltatrice.

In proposito deve ancora precisarsi che, se appare in astratto condivisibile l'affermazione del primo giudice secondo cui, una volta modificata dal CP_1 la domanda di adempimento contrattuale in domanda di risoluzione a norma dell'art. 1453, secondo comma c.c., l'attore non poteva nuovamente richiedere la condanna della convenuta all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto, non appare tuttavia corretta la conclusione del tribunale, che si è limitato a pronunciare la risoluzione del contratto di appalto del 13-7-1992 per l'inadempimento della CP_5 dichiarando inammissibili o comunque respingendo tutte le altre domande dell'attore.

Come è noto, la risoluzione, a norma dell'art.1458 c.c., ha effetto retroattivo tra le parti, in quanto toglie valore alla causa giustificativa delle prestazioni patrimoniali già eseguite, che devono pertanto essere restituite. In tema di risoluzione del contratto di appalto, qualora la risoluzione consegua all'inadempimento del committente e non sia configurabile la restituzione in natura alla impresa appaltatrice della costruzione parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l'appaltatore si era determinato a concludere il contratto (v. Cass. n. 12162 del 24 maggio 2007, n.738 del 15-1-2007).

L'appello del CP_1 è dunque parzialmente fondato, e la sentenza di primo grado va conseguentemente riformata con la condanna della CP_5 al pagamento in favore dell'appellante della complessiva somma di lire 63.000.000, corrispondenti a euro 32.536,78, oltre interessi, nella misura legale dal giorno della domanda al saldo. Non può invece accogliersi la domanda del CP_1 di restituzione dell'assegno di lire 56.000.000 di cui si è detto, in quanto il titolo venne rilasciato a Persona_1 padre della odierna appellata, terzo estraneo al presente giudizio.

Deve infatti disattendersi l'appello incidentale della CP_5 che invoca gli artt. 1659 e 1661 c.c. per sentir dichiarare inammissibile la prova testimoniale espletata e di conseguenza la illegittimità delle varianti apportate al progetto originario, poi regolarmente condonate, al fine di affermare l'inadempimento dell'appaltatore, o almeno di giustificare il proprio. Dalla prova orale era emerso che la CP_5 si recava spesso presso il cantiere, sia da sola che accompagnata dai propri genitori, e deve pertanto presumersi che fosse a conoscenza delle modifiche di volta in volta realizzate, tanto che anche lei stessa si sarebbe resa promotrice di una richiesta di variante, poi non eseguita, volta a

realizzare una palestra al posto dei previsti garages. In definitiva può ritenersi che le varianti-la cui eventualità era del resto espressamente prevista nel contratto di appalto- siano state in concreto concordate dalle parti, o comunque realizzate dal CP_1 con il consenso talora anche tacito della CP_5 che in seguito le avrebbe utilizzate come pretesto per non pagare quanto dovuto, secondo quanto risulta dalla corrispondenza in atti. È appena il caso di ricordare che la prova scritta della autorizzazione del committente alle variazioni dell'opera appaltata è necessaria soltanto quando le variazioni siano dovute alla esclusiva iniziativa dell'appaltatore (v.Cass.n.3040 del 1995), circostanza che alla luce di quanto fin qui esposto appare tutt'altro che pacifica nel caso di specie. La sentenza di primo grado va invece pienamente confermata nella parte in cui respinge le reciproche domande di risarcimento danni. La domanda di risarcimento proposta dalla CP_5 va evidentemente respinta perché il suo comportamento inadempiente ha dato causa alla risoluzione del contratto di appalto. Per quanto invece concerne la domanda del CP_1 deve concordarsi con il tribunale quando afferma che la concessione in sanatoria per le irregolarità urbanistiche imputabili ad esso appaltatore, fu rilasciata solo nel 2001, quando il giudizio di primo grado era in corso da anni, e solo da quel momento sarebbe stato possibile dare corso alla vendita degli appartamenti realizzati: deve comunque presumersi che il notorio aumento del prezzo degli immobili, nella specie di proprietà comune, sia tale da eludere l'incidenza della intervenuta svalutazione monetaria. Allo stesso modo, deve escludersi che la CP_5 sia tenuta a corrispondere la metà degli oneri concessori derivanti dalla domanda di sanatoria, per avere essa solo indirettamente preso parte all'illecito urbanistico, certamente imputabile almeno in pari misura al costruttore, mancando qualsiasi prova in ordine ad una sua specifica richiesta di realizzazione delle opere in variante, successivamente condonate.

Deve da ultimo ritenersi fondata la censura dell'appellante avverso la pronuncia di inammissibilità della domanda di divisione proposta dal CP_1. Premesso che appare quantomeno singolare che nel corso del lungo giudizio di primo grado la domanda di divisione non sembra essere stata coltivata, non essendosi provveduto neppure a predisporre un indispensabile progetto divisionale né ad affidare un incarico in tal senso al CTU, non può assolutamente condividersi l'opinione del primo giudice circa l'applicazione dell'art. 1111 c.c.. Il tribunale ha ritenuto che con l'atto di transazione dell' 11-7-1992 le parti, rinunciando agli effetti della sentenza del tribunale di Rieti che nel 1988 aveva disposto la divisione del solo lotto di terreno, abbiano inteso stipulare un patto di indivisibilità di durata indeterminata, che doveva dunque essere ricondotto alla durata massima decennale, ed ha concluso per la inammissibilità della domanda di divisione per non essere trascorso il decennio dalla data della transazione, al momento della introduzione del presente giudizio. Ma, come correttamente rilevato dall'appellante, nel caso dell'art. 1111 c.c., il decorso del decennio non costituisce

certamente un presupposto processuale bensì una condizione dell'azione, che è sufficiente che sussista al momento in cui la lite viene decisa. Nella specie, il termine era ampiamente decorso al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, risalente al 2003, e deve di conseguenza ritenersi che fosse ormai possibile procedere alla divisione del lotto e del fabbricato sullo stesso realizzato, in applicazione del principio generale secondo cui ciascuno dei partecipanti può sempre chiedere lo scioglimento della comunione. Sul punto è dunque infondato l'appello incidentale della CP_5 che invoca in modo contraddittorio l'autorità di giudicato della sentenza di primo grado del tribunale di Rieti che nel 1988 aveva disposto la divisione del fondo; trattandosi di giudicato esterno, chi ne invoca l'efficacia ha l'onere di fornirne la prova, mentre nella specie non risulta neppure prodotto il dispositivo della sentenza suindicata, né si conosce l'esito della transazione in atti dell' 11-7-1992, in cui le parti si impegnavano ad abbandonare il relativo giudizio di appello e cancellare la trascrizione della sentenza di divisione.

La doglianza del CP_1 è pertanto fondata. Deve però disporsi, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio di divisione, che non può essere deciso in questa sede, non essendo stato predisposto alcun progetto divisionale.

Il regolamento delle spese processuali, ivi compresa la valutazione del motivo di appello del CP_1 avverso la compensazione delle spese del primo grado, va rimandato alla sentenza definitiva”.

Con la seconda sentenza non definitiva n° 2125/14 emessa il 3.3.2014, la Corte di Appello di Roma ha provveduto a disporre la divisione del bene comune tra le parti secondo apposito progetto divisionale elaborato dal consulente tecnico, rimettendo ad ulteriore trattazione le operazioni di divisione.

La Corte di appello di Roma ha disposto “ 1)in riforma della sentenza n°466/03 del Tribunale di Rieti, sezione civile depositata il 25 giugno 2003, accoglie la domanda proposta da [...] CP_1 e dichiara la divisibilità del terreno sito in località Santa Rufina del comune di Cittaducale, distinto in catasto al fogli 6, particella 576 di mq 12.740 circa con annesso fabbricato per civile abitazione allo stato di rustico, da effettuarsi secondo il progetto di divisione n°3 predisposto dal ctu il 9 luglio 2013;2) dispone per l'ulteriore prosecuzione come da separata ordinanza in pari data; 3)spese al definitivo”.

La sentenza è così motivata: “Va innanzitutto disposto non luogo a provvedere sulla domanda di correzione dell'errore materiale, avanzata ex art. 287 c.p.c. dal CP_1 con comparsa depositata il 10 giugno 2010, avendovi già provveduto questa corte con provvedimento depositato il 19 ottobre 2010.

Va quindi sottolineato, ancora in via preliminare, che la presente controversia viene all'esame di questa corte per la decisione sulla domanda di divisione proposta dal CP_1 avendo la corte già

affermato con la ricordata sentenza n° 2106/10 (ed in riforma anche sul punto della sentenza n° 466/03 del Tribunale di Rieti) l'ammissibilità della domanda per essere decorso, al momento della decisione di primo grado, oltre un decennio dalla transazione stipulata l'11 luglio 1992 tra il CP_1 e la CP_5 cfr. la copia di tale atto, allegata sub doc. 4 al fascicolo di parte appellata per il primo grado) che, tra l'altro, avevano rinunciato all'efficacia della sentenza 255/88 del Tribunale di Rieti che aveva dichiarato lo scioglimento della comunione e rimesso le parti dinanzi al giudice istruttore per le operazioni di sorteggio (cfr. la copia di tale sentenza, allegata sub doc. 3 al fascicolo di parte appellata per il primo grado). Come è noto, il giudizio divisorio si scinde in due fasi: la prima di tali fasi ha ad oggetto l'accertamento del diritto spettante a ciascun partecipante sul bene comune, con il conseguente accertamento del diritto alla divisione; la seconda invece - che presuppone che sia stato affermato il diritto alla divisione - ha ad oggetto l'attuazione di tale diritto, ovverossia l'individuazione del contenuto specifico del diritto spettante a ciascun condividente (così Cass. n° 11293/98). Ed infatti, il fine primario della divisione è la conversione, del diritto di ciascun condividente alla quota ideale, in diritto di proprietà esclusivo di beni individuali ed il limite innanzitutto stabilito rispetto a tale diritto è che il bene oggetto di divisione possa essere "comodamente divisibile" come espressamente previsto dall'art. 1114 c.c. (così Cass. n° 22906/06 che ha sottolineato che è possibile l'assegnazione di un bene non comodamente divisibile anche ai titolari di una quota minore in presenza di una pluralità di richieste di assegnazione e laddove ciò corrisponda all'interesse comune delle parti). La giurisprudenza ha in proposito sottolineato che il predetto requisito, della comoda divisibilità del bene ai sensi degli art. 1114 c.c. e 720 c.c. (applicabile allo scioglimento di qualsiasi divisione per effetto del richiamo operato dall'art. 1116 c.c.), postula, sotto l'aspetto economico finanziario, che il frazionamento sia attuabile mediante la determinazione di porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non gravate, almeno di norma, da pesi, servitù e limitazioni eccessive, e che possano formarsi senza la necessità di fronteggiare problemi tecnici troppo costosi e particolarmente complessi (così Cass. n° 1104/90) ed inoltre che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole porzioni rispetto al valore dell'intero (così Cass. n° 1260/95). Si è altresì sottolineato, sempre con riferimento al concetto della comoda divisibilità, che l'unitaria destinazione economica del bene comune non ne esclude la comoda divisibilità, ai sensi degli art. 720 e 1114 c.c., se il bene può essere materialmente ripartito senza pregiudizio dell'originario valore economico, in parti vantaggiosamente utilizzabili dai singoli condividenti (così Cass. n° 2117/95) il cui valore non sia sensibilmente inferiore (se rapportate all'intero) tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (così Cass. n° 12498/07 e Cass. n° 14540/04) ed anche ove sia necessario il ricorso al correttivo dei conguagli in denaro previsto dall'art. 728 c.c. (così la

citata Cass. n° 2117/95). Con riferimento al caso di specie non vi è dubbio sulla possibilità che il bene di cui il CP_1 e la CP_5 sono comproprietari al 50 % possa essere oggetto di comoda divisione - come del resto già affermato dal Tribunale di Rieti nella citata sentenza n° 255/88 - in due porzioni materialmente distinte tra loro, come del resto dimostra la circostanza che rispetto al medesimo bene sono stati realizzati ben tre progetti di divisione che ne consentivano la materiale ripartizione nel rispetto dei principi codicistici (realizzazione di porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non gravate da pesi, servitù e limitazioni eccessive, che possano essere formate senza la necessità di fronteggiare problemi tecnici troppo costosi e particolarmente complessi e che ne consentano l'utilizzazione secondo l'originaria destinazione del bene e senza determinare un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote) sopra indicati. Non vale in contrario a ciò sostenere, come fa la CP_5 che la indivisibilità del bene in questione - costituito da una porzione di terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato al rustico - deriverebbe dalla unitarietà del provvedimento concessorio, necessario per la ultimazione del bene. Ed infatti, come già sopra specificato, la non divisibilità (o non comoda divisibilità) del bene va affermata con riferimento alla situazione concreta e materiale di esso e non già ad una situazione di diritto: nel caso che ci occupa l'edificio realizzato solo parzialmente dai comunisti è certamente suscettibile, anche allo stato, di materiale divisione, mentre gli ulteriori aspetti pratici della vicenda (necessità, come sostenuto dalla CP_5 nella sua seconda comparsa conclusionale, che questa Corte affermi la "scindibilità" della originaria concessione edilizia ovvero che subordini la divisione ad un "regolamento" che consenta alle due parti assegnatarie di coordinare l'esecuzione dei lavori) sono questioni ultronee (si ricorda che la divisione va realizzata all'attualità, tanto che l'eventuale conguaglio in denaro costituisce debito di valore e va determinato con riferimento al valore del bene rapportato al momento della divisione: così Cass. n° 2914/90) e riguardano aspetti estranei al presente giudizio (che sarà onere delle parti regolare successivamente tra loro e con le competenti autorità). Per quanto sin qui detto, va dunque accolta la domanda proposta da Controparte_1 ed affermata la divisibilità del bene oggetto di comproprietà tra il medesimo CP_1 e Controparte_5.

Rileva quindi questa corte che tra i diversi progetti di divisione predisposti dal nominato ctu, va data preferenza a quello denominato come n° 3, redatto il 9 luglio 2013, come del resto richiesto dalla CP_5 nella sua quarta comparsa conclusionale, progetto che del resto non può non trovare anche il consenso del CP_1 che, nelle sue conclusioni, ha chiesto che la divisione venisse realizzata "secondo il progetto di divisione predisposto dal ctu che realizzi la più radicale separazione fisica tra le due quote e meglio rispondente ai criteri codicistici". Sottolinea in proposito questa corte che con tale ultimo progetto - come si evince dalla planimetria allegata alla relazione - il nominato perito ha realizzato la separazione più radicale tra le due quote che, a parte l'utilizzo

della rampa comune di accesso ai box, sono nettamente distinte tra loro ed ha di conseguenza dovuto quantificare in una somma maggiore rispetto ai precedenti progetti di divisione (nei quali al fine di contenere l'entità di tale conguaglio il perito aveva provveduto ad una separazione meno netta e meno omogenea del bene in due quote) l'entità del conguaglio, a carico della quota denominata B ed a favore di quella denominata A, pari ad euro 69.775,00 determinato all'attualità.

Va infine disposta la comparizione personale delle parti, ai sensi dell'art. 789 c.c. come da separata ordinanza.

La liquidazione delle spese va riservata all'ulteriore esito delle operazioni necessarie alla divisione”.

La CP_5 ha proposto ricorso per cassazione avverso ambedue le sentenze non definitive rese dalla Corte romana, articolando otto motivi di censura. Ha resistito con controricorso il CP_1 ed ambedue le parti hanno depositato memorie difensive.

Il Supremo Collegio ha così statuito: “*Accoglie l'ottavo motivo di ricorso, rigetta i primi cinque motivi e dichiara assorbiti il sesto ed il settimo motivo, cassa la sentenza della Corte d'Appello di Roma n° 2106/10 resa il 1.12.2009 e rinvia alla Corte d'Appello di Roma altra sezione in relazione a quanto accolto anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità”.*

La Suprema Corte ha motivato la decisione come di seguito riportato: “*Il ricorso proposto da Controparte_5 ha parziale pregio giuridico ed in tal misura va accolto. In limine deve la Corte rilevare l'infondatezza dell'eccezione circa la tardività del proposto ricorso - in relazione alla sentenza n° 2106/10 - sollevata dal CP_1 in quanto detta sentenza da ritenersi di carattere parziale poiché definiva completamente dei temi di lite e, non già, da ritenersi sentenza non definitiva, con possibilità di riserva dell'impugnazione. In conseguenza a detta riqualificazione del provvedimento impugnato, risultava scorso il termine di decadenza dall'impugnazione al momento della notifica del ricorso per cassazione. L'eccezione svolta appare priva di fondamento giuridico e va disattesa.*

Difatti, come costantemente insegna questo Supremo Collegio - Cass. SU n° 711/1999, Cass. sez. 2 n° 4618/07, Cass. sez. 3 n° 28467/13 -, lo scrimine utile all'individuazione della sentenza non definitiva rispetto a quella parziale ha carattere meramente formale e, non già, sostanziale attraverso una valutazione della natura e struttura delle questioni decise, siccome pare opinare parte resistente. Nella specie, la Corte romana non solo ebbe a definire espressamente siccome sentenza non definitiva il provvedimento adottato sub n° 2106/10, ma pure non ebbe né a separare i giudizi, né a statuire sulle spese elementi formali tipici, secondo al richiamato insegnamento di legittimità, della sentenza non definitiva. Va poi rilevata l'inammissibilità del deposito documentale effettuato dalla CP_5 con la nota difensiva, poiché trattasi di documento non previsto dalla norma ex art 372 cod. proc. civ.

Con il primo mezzo d'impugnazione proposto la ricorrente denuncia violazione delle disposizioni normative ex art 1111, 1112 e 1965 cod. civ. nonché art 324 cod. proc. civ. in relazione alla

statuizione del Collegio romano circa la ritenuta ammissibilità della domanda di divisione del bene comune.

Osserva la CP_5 come, con l'accordo di natura transattiva del 1992, il CP_1 non già, ebbe ad assumere impegno di non chiedere la divisione, bensì a rinunciare all'azione tesa alla divisione, sicché detta azione giudiziale non può più esser proposta.

Inoltre osservava come il patto di rimanere in comunione, per la durata consentita dalla legge, si prospetti, non già, quale condizione dell'azione, bensì presupposto processuale. Non sussiste la dedotta violazione di legge sotto entrambi i profili lumeggiati in ricorso.

Difatti, come anche ricorda la stessa impugnante, ex art 1111 comma 1 cod. civ., è facoltà del comunista poter sempre chiedere la divisione del bene comune, sicché la rinuncia all'azione intrapresa per pervenire alla divisione del bene comune non comporta il venir meno definitivo della facoltà di chiedere la divisione, poiché così previsto dalla legge.

Quanto poi alla natura di presupposto processuale del patto di non chiedere la divisione, disciplinato dalla norma in comma 2 art 1111 cod. civ., va rilevato come detto patto non già condiziona la validità dell'instaurato procedimento – natura propria della situazione qualificata siccome presupposto processuale -, bensì solo la possibilità dell'attore di ottenere sentenza favorevole - natura propria della condizione dell'azione -.

Difatti, entro il termine decennale dalla pattuizione, il Giudice dovrà rigettare la domanda di divisione proposta, mentre se la pronunzia interviene scorso detto termine, nulla osta alla decisione favorevole.

L'argomento critico portato dalla CP_5 per individuare nel patto di rimanere in comunione un presupposto processuale si fonda sull'osservazione che la disposizione in comma secondo opera riferimento alla norma portata nel primo comma, che disciplina il diritto del comunista di domandare, anche, giudizialmente la divisione. In effetto però il disposto ex comma 2 art 1111 cod. civ. si limita a disciplinare l'eccezione alla libertà della parte di chiedere la divisione, rappresentata dalla durata del patto di rimanere in comunione, senza cenno alcuno alla facoltà di agire in giudizio di cui al primo comma. Con la seconda ragione di doglianza la CP_5 rileva violazione della norma ex art 112 cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza adottata dalla Corte romana poiché non fu valutata la sua eccezione, fondata sul giudicato ostativo portato nella sentenza resa dal Tribunale di Rieti nel 1988, in relazione alla precedente domanda di divisione svolta dal CP_1

Il dedotto vizio non sussiste atteso anche la stessa argomentazione critica, esposta dalla CP_5 in ordine al primo motivo d'impugnazione, con la quale si duole della valutazione data dal Collegio romano proprio alla sua tesi difensiva fondata sul giudicato rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Rieti del 1988 e dalla successiva transazione.

Inoltre la Corte territoriale ha puntualmente rilevato come non vi sia adeguata prova del dedotto giudicato ed al riguardo la CP_5 se indica l'esistenza in atti del dispositivo della sentenza di prime cure, nulla deduce con relazione all'esito del giudizio d'appello, nelle cui more intervenne la transazione, pure elemento probatorio ritenuto rilevante ai fini di ritenere sussistente il dedotto giudicato. Dunque non sussiste la denunziata omessa pronunzia sull'eccezione avanzata, poiché invece detta questione risulta appositamente esaminata dalla Corte distrettuale.

Con la terza ragione di doglianza la ricorrente lamenta violazione delle norme ex art 1111 e 1112 cod. civ. in quanto il Collegio romano non ebbe ad adeguatamente considerare l'incidenza, anche sotto il profilo del valore economico del bene comune, della natura unitaria del titolo amministrativo abilitativo alla realizzazione della costruzione sul lotto comune di terreno edificabile.

L'argomentazione critica, veicolata sotto il profilo della violazione di legge, in effetti consiste nella riproposizione della, tesi difensiva, già motivatamente disattesa dalla Corte territoriale, senza un effettivo confronto con le argomentazioni esposte dai Giudici romani in sentenza n° 2125/2014.

In detto provvedimento, pure oggetto d'impugnazione, risulta appositamente esaminata l'incidenza della concessione ad edificare unitaria sulla divisibilità in concreto del bene, e la Corte distrettuale ebbe a motivatamente escludere un tanto.

Quanto poi alla questione dell'incidenza della disposta divisione sul valore economico del bene assegnato a ciascun comunista rispetto al valore del bene unitario, la stessa s'appalesa siccome nuova in questa sede poiché la CP_5 non specifica, nella sua argomentazione critica, quando e come la stessa fu prospettata al Giudice d'appello, limitandosi a lamentare genericamente una omessa considerazione della questione.

Con il quarto mezzo d'impugnazione la ricorrente deduce violazione delle regole di diritto desumibili dagli artt. 183, 184 e 194 cod. proc. civ. in tema di documentazione esaminabile e valutabile da parte del consulente tecnico, posto che la Corte ebbe a ritenere legittima l'acquisizione di documentazione - non versata dalle parti - da parte del consulente nell'ambito del suo incarico.

La censura risulta priva di pregio, in primo luogo, perché trattandosi di nullità sanabile, ex art 157 cod. proc. civ. - Cass. sez. 3 n° 15747/18 -, era specifico onere - non adempiuto - dell'impugnante precisare di aver sollevata tempestiva eccezione al riguardo nel corso della trattazione istruttoria non appena verificatasi la dedotta irregolarità. In secondo luogo è consentito, secondo l'insegnamento di questo Supremo Collegio richiamato appositamente dalla Corte romana - conf. Cass. sez. 1 n° 15774/18 -, al consulente l'acquisizione di informazioni necessarie alla compiuta risposta ai quesiti posti, come ha motivatamente ritenuto la Corte romana essere avvenuto nella specie.

A fronte di detta motivazione l'impugnante si limita a svolgere argomentazione meramente alternativa, operando cenno ad alcuni dei documenti acquisiti dal consulente presso Pubblici Uffici, che appunto lumeggiano la necessità della loro acquisizione al fine di compiuta risposta ai quesiti posti dal Giudice.

Con la quinta doglianza la CP_5 deduce omesso esame di fatto decisivo, ex art 360 n° 5 cod. proc. civ., che viene individuato nella carenza delle conclusioni ed argomentazioni illustrate dal consulente tecnico, fatte proprie ai fini della decisione, dalla Corte d'Appello.

All'evidenza non ricorre il vizio denunziato, che afferisce all'omesso esame di un fatto e, già, all'omessa valutazione di un mezzo istruttorio, siccome insegna costantemente questa Suprema Corte - Cass. SU n° 8053/14 -, di qui l'inammissibilità della censura.

Le censure svolte dalla CP_5 sub numeri sei, sette ed otto attengono alla questione correlata al contratto d'appalto intercorso tra le parti ed effettivamente la doglianza mossa con l'ottavo mezzo d'impugnazione appare fondata e va esaminata prioritariamente sulle censure mosse con i motivi sei e sette, che rimangono assorbite in dipendenza di tale accoglimento.

Con l'ottava doglianza la CP_5 lamenta violazione delle norme sostanziali circa la disciplina dell'appalto in relazione alla ritenuta ammissibilità, prima, ed utilizzabilità, poi, della prova testimoniale circa l'esistenza di accordo tra le parti contrattuali relativamente alle variazioni al progetto eseguite dall'appaltatore. La ricorrente osserva come la Corte capitolina abbia utilizzato la prova orale espletata e la prova per presunzioni per concludere come non risultava assodato che le variazioni al progetto eseguite fossero da ricondurre alla sola volontà dell'appaltatore con conseguente non applicabilità del disposto ex art 1659 cod. civ. in punto prova scritta - Cass. sez. 2 n° 19099/11-.

Così statuendo il Collegio romano, effettivamente, non s'è attenuto al disposto ex art. 1659 cod. civ. siccome denunziato dalla CP_5 posto che deve essere certo che le variazioni al progetto furono disposte da committente ovvero di comune accordo tra le parti per aversi applicazione della norma ex art 1661 cod. civ. comportante anche la libertà di prova.

Viceversa il Giudice d'appello, sulla scorta dell'apprezzamento degli esiti della prova orale - presenza frequente in cantiere della CP_5 e richiesta di una variante poi non realizzata - e di argomenti logici dall'esito di detta prova desunti - conoscenza delle varianti eseguite dal cugino appaltatore e previsione contrattuale di esecuzione di varianti - ha concluso che risultava "tutt'altro che pacifica" la circostanza dedotta dalla CP_5 che le varianti furono eseguite d'iniziativa dall'appaltatore CP_1 con la conseguente ricaduta sull'onere probatorio.

Difatti era onere probatorio dell'appaltatore dimostrare che le variazioni erano state disposte dal committente ovvero concordate, poiché al riguardo trova applicazione la norma ex art 1659 cod. civ.

- prova scritta - dell'accordo raggiunto sul punto dalle parti contrattuali ovvero disposizione specifica impartita dal committente, nella specie mancante.

Non assume rilievo l'osservazione del CP_1 che egli cumulava la posizione di committente ed appaltatore sicché poteva disporre le varianti realizzate, posto che l'impegno assunto contrattualmente con la cugina CP_5 lo poneva, nei riguardi della stessa, nella sola posizione di appaltatore, con i conseguenti obblighi. Quindi la sentenza n° 2106/10 - che ebbe a statuire sul punto - va cassata in relazione alla questione circa la prova scritta - necessaria stante il contrasto sul punto tra le parti - che l'eseguite varianti del progetto furono disposte dalla committente CP_5 ovvero concordate.

Le doglianze svolte sub motivi sei e sette dalla CP_5 afferiscono a nullità della sentenza per aver la Corte capitolina omesso di valutare alcune argomentazioni difensive, relative all'inadempimento imputato, ovvero a violazione delle regole di diritto in tema di adempimento delle obbligazioni ed omesso esame su un punto decisivo sempre in tema di ritenuto suo inadempimento.

L'accoglimento dell'ottavo motivo di ricorso comporta la cassazione, in parte qua - contratto d'appalto -, della sola sentenza non definitiva n° 2106/2010 resa dalla Corte d'Appello di Roma ed il rinvio per nuovo esame alla medesima Corte altra sezione, che provvederà pure a disciplinare le spese di lite di questo giudizio di legittimità”.

Con atto di citazione in riassunzione Controparte_1 ha formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adita Corte pronunciarsi conformemente a quanto indicato dalla S.C. con la sentenza n. 15177/2019 resa su ricorso n. 13175/2015 della CP_5 e conseguentemente:

«Statuire in relazione alla questione circa la prova scritta - necessaria stante il contrasto sul punto tra le parti - che le eseguite varianti del progetto furono disposte dalla committente CP_5 ovvero concordate» e, dunque « ... in relazione a quanto accolto anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità» in ossequio alla decretata «cassazione (a seguito dell'accoglimento dell'ottavo motivo di ricorso) in "parte qua" - contratto di appalto - della sola sentenza non definitiva n. 2106/2010 resa dalla Corte di Appello di Roma».

Il tutto, previa consulenza tecnica necessaria per individuare e valutare le "varianti realizzate" e il relativo "costo" da riconoscersi nella misura del 50% alla CP_5 per il fatto d'essere proprietaria del 50% dell'immobile tuttora indiviso, diffalcando il relativo importo dai € 32.536,78 euro, oltre interessi riconosciuti, a favore del CP_1 dalla sentenza n. 2106/2010, tenuto conto del vantaggio trattone dalla CP_5

-Disporre comunque la divisione del lotto di terreno sito in Santa Rufina di Cittaducale, distinto in catasto al foglio 16 particella 576, confinante con la SS4 Salaria per L'Aquila, Caprioli e Per_2 della superficie di mq 12.740 circa, e della struttura al grezzo su di esso realizzata dall CP_6

[...] su progetti dell' Ing. Persona_3 e in virtù delle concessioni edilizie 3-4-1980 n. 295 e n. 23 del 10.10.2001 rilasciate dal Comune di Cittaducale. Tutto ciò, secondo quanto indicato dalla Corte con l'ordinanza del 03.03.2014 resa nel giudizio 11601/2003» previa riunione a questo giudizio di quello riveniente dall'istanza di prosecuzione di quel giudizio. Con vittoria di spese”.

Si è costituita in giudizio Controparte_5 che ha così concluso: “piaccia alla Corte di Appello, in accoglimento delle conclusioni formulate con la comparsa di costituzione nel giudizio n. 11601/03 r.g.c. con contestuale appello incidentale della convenuta Controparte_5 nei confronti della sentenza n. 466/03 del Tribunale di Rieti e con rigetto delle richieste avversarie, in via istruttoria preliminare rimettere la causa sul ruolo al fine della integrazione della CTU già richiesta, alla luce dei rilievi svolti e della necessità di precisare la datazione delle opere realizzate dal CP_1 e della maturazione dei suoi crediti, anche previa depurazione di essi dalle somme reclamate a fronte delle opere aggiuntive ed in variante rispetto al progetto, in nessun caso pagabili per violazione degli articoli 1659 e 1661 c.c., ponendoli a confronto con la datazione dei versamenti eseguiti dalla CP_5 nonché per la quantificazione degli ulteriori danni subiti dalla CP_5 vuoi per le maggiori spese occorrenti per acquisire i nuovi provvedimenti autorizzativi del completamento dei lavori e per le opere relative nonché per il ritardo anche conseguente ai tempi necessari per il giudizio d'appello introitato dal CP_1 nel merito –previa revoca della ordinanza ammissiva della prova testimoniale richiesta da parte attrice e dichiarazione di inutilizzabilità delle verbalizzazioni raccolte in attuazione di essa e declaratoria di inutilizzabilità di tutti i documenti intempestivamente ed irritualmente prodotti dal CP_1 A) annullare la dichiarazione di risoluzione del contratto per colpa della convenuta CP_5 e quella di condanna al pagamento di somme pronunciata dalla sentenza 2016/10 della Corte di Appello di Roma; B) dichiarare la risoluzione del contratto di appalto stipulato inter partes il 13.7.92 per grave inadempienza del CP_1 C) condannare comunque l'attore alla riduzione in pristino dell'edificio per adeguarlo al progetto originario, oggetto di contratto, a sue esclusive cura e spese (anche con riferimento ai necessari atti amministrativi) eliminando le opere abusive, i vizi e le difformità; D) condannare in ogni caso il CP_1 al risarcimento dei danni prodotti alla CP_5 con il suo comportamento sia sotto il profilo della violazione delle sue obbligazioni contrattuali che sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale (per quanto occorrente, previa declaratoria incidentale della illegittimità della condono/sanatoria e della non collaudazione e collaudabilità dell'edificio e sua connessa non commerciabilità), danni quantificati nella misura di € 900.000,00 (o in quella diversa che dovesse essere tenuta provata e/o di giustizia), da rivalutarsi e maggiorarsi degli interessi dalla domanda al saldo; E) condannare il CP_1 al pagamento delle spese (tra cui quelle della C.T.U. e della C.T.P.)

e competenze tutte di lite, relative al giudizio di appello, a quello di Cassazione e del presente grado di giudizio, comprensive della maggiorazione del 15%, del contributo CNPA e dell'IVA".

A scioglimento della riserva assunta in data 21.10.2020, la Corte ha rigettato l'istanza di riunione avanzata da *Controparte_1* relativa alla causa Rg n. 11601/2003 e disposto c.t.u.

Successivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 giugno 2023, la Corte, ritenuta l'opportunità di disporre la comparizione personale delle parti al fine di tentare la conciliazione della lite, ha rinviato la causa per la comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione.

Infine, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05-12-2023, la Corte preso atto della mancata comparizione di *Controparte_8* all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione tra le parti ha assegnato al CTU termine per il deposito di una sintetica valutazione delle osservazioni e controdeduzioni allegate alla relazione definitiva.

All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.

Pare opportuno in via del tutto preliminare, illustrare sinteticamente i principi disciplinanti il giudizio di rinvio. Come è noto, nel giudizio di rinvio, che costituisce una nuova fase del processo, autonoma rispetto alle precedenti, finalizzata alla sostituzione della sentenza cassata, l'oggetto della controversia è chiuso e circoscritto nei limiti segnati dalla pronuncia di annullamento della Corte e sulle questioni da essa decise (Cass. 7 novembre 2003, n. 16694; Cass. 22 maggio 2006, n. 11939; Cass. 7 marzo 2011, n. 5381; Cass. 5 aprile 2013, n. 8381; Cass., Sez. Lav., 29 maggio 2014, n. 12102; Cass. 5 aprile 2016, n. 6552).

Ne consegue che: per un verso, le parti non possono ampliare oltre tali limiti l'oggetto del giudizio di rinvio; per altro verso, il giudice non può riesaminare gli antecedenti logici e giuridici delle questioni decise e non può procedere a una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso, ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità, ed è tenuto ad uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella pronuncia della Corte di Cassazione e a quanto ivi statuito, stante il disposto dell'art. 384, comma 1, c.p.c., non potendone sindacare la giuridica correttezza né in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, né alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della S.C.

In altri termini, il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur essendo dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo e ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario.

Si tratta, quindi, di un giudizio chiuso, nel quale il giudice del rinvio deve limitarsi a completare il sillogismo giudiziale e ad applicare il "dictum" della Cassazione a un materiale di cognizione già

completo.

Ciò premesso nel caso di specie l'oggetto del presente giudizio è limitato, a quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo la quale: *“era onere probatorio dell'appaltatore dimostrare che le variazioni erano state disposte dal committente, ovvero concordate, poiché al riguardo trova applicazione la norma ex art. 1659 cod.civ. – prova scritta – dell'accordo raggiunto sul punto dalle parti contrattuali ovvero disposizione specifica impartita dal committente, nella specie mancante. Non assume rilievo l'osservazione del CP_1 che egli cumulava la posizione di committente ed appaltatore sicché poteva disporre le varianti realizzate, posto che l'impegno assunto contrattualmente con la CP_5 lo poneva, nei riguardi della stessa, nella sola posizione di appaltatore, con i conseguenti obblighi. Quindi la sentenza n. 2106/10 – che ebbe a statuire sul punto – va cassata in relazione alla questione circa la prova scritta – necessaria stante il contrasto sul punto tra le parti – che l'eseguite varianti del progetto furono disposte dalla committente CP_5 ovvero concordate”*.

Orbene, la norma che viene all'esame nel caso di specie è quella dettata dall'art. 1659 c.c. a mente del quale *“L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione si deve provare per iscritto”*.

Anche recentemente, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo il quale: *“In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente; mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente”*. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 40122 del 15/12/2021 conformi: Cass. n. 19099 del 2011. Ed anche *“In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente poiché, nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", mentre, nel secondo, l'art. 1661 c.c. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente”*. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 32989 del 13/12/2019.

Pertanto, per quanto concerne l'adempimento dell'onere probatorio non essendovi prova che l'iniziativa per le varianti fosse partita dalla CP_5 spettava all'appaltatore Controparte_1 provare per iscritto l'autorizzazione fornita dalla committente.

Tale prova scritta non risulta presente in atti. Infatti, il CP_1 ha provveduto a depositare il contratto

originario di appalto stipulato tra le parti e l'istanza presentata al Sindaco di Città Ducale (sottoscritta unicamente dal CP_1 avente ad oggetto la variante al progetto per la costruzione dell'edificio per cui è causa (cfr. allegato 17).

Invero, come sopra riportato, la Suprema Corte ha evidenziato la non identificabilità del CP_1 nella figura del committente, ma esclusivamente in quella dell'appaltatore (nei suoi rapporti con la CP_5 come si evince anche dal contratto di appalto del 13/07/1992, (cfr. allegato 14) dove risulta committente la sola Controparte_5 .

Sicché, in assenza della prova scritta dell'autorizzazione della CP_5 in merito alle varianti realizzate dall'appaltatore sull'immobile oggetto di giudizio vanno rigettate la domanda di risoluzione avanzata dal CP_1 nonché la domanda di condanna della CP_5 al pagamento della differenza ancora dovuta, in considerazione del fatto che il calcolo effettuato dal CTU nel secondo grado di giudizio riguarda tutte le opere incluse quelle in difformità (ovvero le varianti non autorizzate).

Dalla mancata prova del credito vantato dal CP_1 discendono altre conseguenze, ovvero che la CP_5 non è tenuta a corrispondere all'appaltatore le somme previste per le opere realizzate che non erano contemplate nel progetto iniziale. L'appaltatore, infatti, avendo contravvenuto al divieto imposto dal 1659 c.c. 1° comma non può pretendere dalla committente alcun supplemento sul prezzo convenuto. La ratio del menzionato articolo, del resto, mira da un lato ad evitare che l'appaltatore realizzi un'opera diversa da quella concordata con il committente e dall'altro che quest'ultimo si trovi a sostenere spese che non sono state in precedenza preventivate.

In ossequio a quanto statuito dalla Suprema Corte nel giudizio di Cassazione, la quale ha accolto l'ottavo motivo di ricorso della CP_5 non trova accoglimento la domanda di restituzione avanzata dal CP_1 Tuttavia, posto che il sesto e il settimo motivo del ricorso attengono alla questione dei reciproci inadempimenti per stabilire quale sia quello prevalente, siffatti motivi meritano una trattazione congiunta.

In caso di inadempienze reciproche, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento, il giudice di merito deve procedere ad un esame del comportamento complessivo delle parti, per stabilire quale di esse, in base ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale.

Tutto ciò ha come conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia reputato prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente.

Sul punto la Suprema Corte ha anche di recente precisato che: *“In tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale”*. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 14030 del 26/05/2025.

Orbene, nel caso di specie ed alla luce di quanto sin qui rilevato reputa la Corte che nessuno dei due inadempimenti accertati sia stato di entità tale da raggiungere la misura di gravità richiesta per la risoluzione.

Nel caso di specie se è vero che a seguito delle varianti apportate al progetto iniziale mai autorizzate per iscritto dalla CP_5 il CP_1 ha eseguito un'opera edilizia di forme rispetto al progetto iniziale e quindi in violazione dell'accordo contrattuale raggiunto, la domanda di risoluzione avanzata dalla committente non può essere accolta in ragione della natura stesse delle varianti apportate in corso d'opera che di fatto e purtuttavia hanno pacificamente determinato un incremento di valore del bene. Infatti e, relativamente alla domanda di rimessione in pristino avanzata dalla CP_5 occorre osservare che secondo quanto emerso dalla CTU in sede di rinvio le varianti non hanno comportato alcuna diminutio. Nella CTU del presente grado, infatti, si legge: *“Sostanzialmente, la maggiore superficie coperta e le maggiori superfici pertinenziali effettivamente realizzate, anche al netto delle finiture finali del complesso edilizio delle quali non è stata trovata alcuna informazione, non hanno comunque determinato un minusvalore dell'immobile sia in relazione alla ipotizzata minore appetibilità e collocabilità sul mercato delle unità abitative che per ragioni intrinseche (architettoniche o funzionali) e per le mutate tendenze del mercato immobiliare”*. Ed in risposta al quesito n. 6 che rimanda al punto n. 8.8. il ctu afferma: *“...Ciò che è stato costruito è comunque un edificio per abitazioni civili (a confronto con quanto doveva essere realizzato in maniera conforme alla Concessione edilizia del 1980) con delle superfici e volumetrie diverse da quelle inizialmente definite dove le attuali superfici degli appartamenti (aumento della superficie coperta e della superficie dei balconi) non risultano variate in maniera determinante. Come riportato nel paragrafo 8.4., le difformità dell'immobile rispetto al progetto originario non si ritengono emendabili sia dal punto di vista statico che dal punto di vista economico. Gli effetti architettonici o funzionali delle modifiche apportate alla costruzione hanno una origine soggettiva e non hanno una deduzione oggettiva e analitica. Sulla eventuale minore appetibilità sul mercato del manufatto e delle singole unità abitative non ci si può pronunciare in quanto, in sostanza, non è cambiata la natura degli immobili in questione. Analogamente, la collocabilità sul mercato è la stessa in quanto le variazioni apportate non hanno modificato la tipologia di bene eventualmente da vendere. Si tratta comunque*

di appartamenti residenziali composti da 3-4-5 locali più servizi per i quali, considerando la situazione variata rispetto all'originale, nella documentazione agli atti non si hanno indicazioni sulle finiture dell'immobile e delle singole unità abitative presenti (nell'edilizia residenziale le finiture influiscono notevolmente sul valore economico finale dell'immobile)."

Alla luce di quanto sopra riportato, quindi, poiché le varianti non hanno comportato alcuna deminutio ma anzi hanno accresciuto il valore del bene come confermato dalla sentenza n. 2125/2014 pronunciata dalla Corte D'Appello di Roma il 03/03/2014, nulla va riconosciuto ulteriormente alla CP_5 che non ha impugnato alcunché e specificamente in punto di divisione.

La predetta sentenza ha così statuito: *"Rileva quindi questa corte che tra i diversi progetti di divisione predisposti dal nominato ctu, va data preferenza a quello denominato come n° 3, redatto il 9 luglio 2013, come del resto richiesto dalla CP_5 ella sua quarta comparsa conclusionale, progetto che del resto non può non trovare anche il consenso del CP_1 che, nelle sue conclusioni, ha chiesto che la divisione venisse realizzata "secondo il progetto di divisione predisposto dal ctu che realizzi la più radicale separazione fisica tra le due quote e meglio rispondente ai criteri codicistici". Sottolinea in proposito questa corte che con tale ultimo progetto - come si evince dalla planimetria allegata alla relazione - il nominato perito ha realizzato la separazione più radicale tra le due quote che, a parte l'utilizzo della rampa comune di accesso ai box, sono nettamente distinte tra loro ed ha di conseguenza dovuto quantificare in una somma maggiore rispetto ai precedenti progetti di divisione (nei quali al fine di contenere l'entità di tale conguaglio il perito aveva provveduto ad una separazione meno netta e meno omogenea del bene in due quote) l'entità del conguaglio, a carico della quota denominata B ed a favore di quella denominata A, pari ad euro 69.775,00 determinato all'attualità".*

Del resto, e quanto alla condotta tenuta dalla CP_5 va rilevato che la divisione operata dalla Corte d'Appello è stata disposta all'attualità con previsione del conguaglio e quindi ricomprendendo tutto il valore del bene (che ha tenuto conto anche delle varianti mai autorizzate) sicché neppure il suo inadempimento può sin qui reputarsi grave ai fini della declaratoria di risoluzione.

In conclusione la domanda di riduzione in pristino avanzata dalla CP_5 non può trovare accoglimento perché, benché proposta tempestivamente sin dal giudizio di primo grado, la divisione è stata attuata secondo un progetto che ha tenuto conto del maggior valore del bene e su tale aspetto nessuna doglianza è stata spiegata dalla CP_5

In ogni caso neppure merita accoglimento la pretesa risarcitoria, così come formulata dalla CP_5. Ella ha allegato come l'opera oggetto di controversia non fosse destinata a soddisfare proprie esigenze abitative ma che la stessa era invece destinata alla vendita delle unità immobiliari o alla loro locazione e che per effetto della condotta del CP_1 non aveva potuto né alienare, né tantomeno locare gli

immobili, né ottenere altri proventi stante la mancata utilizzazione delle rendite sperate; e, tuttavia, la CP_5 non ha affatto fornito alcun principio di prova, neppure per presunzioni in tal senso e, pertanto, la pretesa dalla stessa avanzata non merita accoglimento.

Né è consentito ritenere di poter accogliere la pretesa risarcitoria della CP_5 nei termini dalla stessa indicati ponendo a fondamento della detta richiesta la CTU espletata posto che come noto la ctu non è un mezzo di prova e come tale non può di certo supplire alle carenze probatorie delle parti.

Era onere della CP_5 invero, quello di provare lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene); e poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti mentre l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ella, trattandosi indubbiamente di circostanze estranea alla sfera di conoscenza del CP_1 ed involvendo invece esclusivamente la sfera di interessi della CP_5 era senz'altro chiamata a fornire la prova del detto pregiudizio anche mediante presunzioni o richiamando le nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; ed in vero il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. (cfr in tal senso Cass. Sentenza n. 33645 del 15/11/2022 (Rv. 666193 - 04).

E, tuttavia, in presenza di reciproche domande di risoluzione contrattuale fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, non potendosi pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve darsi atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma 2, c.c. e deve comunque pronunciarsi la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all'art. 1458 c.c., essendo le due contrapposte manifestazioni di volontà dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale. (cfr. Cass. Ordinanza n. 13118 del 13/05/2024 (Rv. 671136 - 03).

Venendo alle spese di lite, le stesse debbono essere compensate stante la reciproca soccombenza delle parti in relazione a tutti i gradi e fasi interessati dal presente giudizio.

Le spese di ctu rimangono a carico di entrambe le parti al 50%.

P.Q.M

La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2106/2010 pubblicata il 1.12.2009 da parte della sentenza della Corte di Cassazione recante n. 15177/2019, così provvede:

- rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_5 e per l'effetto rigetta la domanda riconvenzionale da questa avanzata;

- rigetta la domanda proposta da *Controparte_1* in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale;
- dichiara risolto il contratto intercorso tra le parti stipulato il 13.7.92;
- rigetta le ulteriori domande proposte;
- compensa integralmente le spese del giudizio di Cassazione, di quello d'appello e del presente di rinvio;
- pone definitivamente le spese di ctu a carico delle parti al 50%.

Così deciso in Roma il 16.09.2025

Il consigliere estensore

-Domenica Capezzer-

Il presidente

-Alberto Tilocca-